

1501052-95.2019.8.26.0452

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... obstáculo ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Nesse sentido: Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito para aplicação da pena base em seu mínimo legal; afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos III e VI, do artigo 40, da Lei de Drogas; reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; fixação de regime prisional ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

2ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju-SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501052-95.2019.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501052-95.2019.8.26.0452

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2311432/2019 - DEL.POL.PIRAJU, 8199853 - DEL.POL.PIRAJU, 1697/19/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2311432 - DEL.POL.PIRAJU, 1697/19/118 - DEL.POL.PIRAJU, 2311432 - DEL.POL.PIRAJU, 1697/19/118 -

DEL.POL.PIRAJU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJALMA LUIZ DE BRITO OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra DJALMA LUIZ DE BRITO OLIVEIRA e ALISSON RAMOS RODRIGUES DA SILVA (fls. 161/162), qualificados nos autos, dando-os como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 17h, na Rua Lourenço Benete, Conjunto Residencial Boa Vista, nesta cidade e comarca de Piraju, DJALMA LUIZ DE BRITO OLIVEIRA e ALISSON RAMOS RODRIGUES DA SILVA, respectivamente qualificados as fls. 15 e 18, guardavam, para fins de tráfico, 92,17 g (noventa e duas gramas e dezessete miligramas) de Cannabis sativa L., vulgo "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Portaria nº 344/98, ANVISA), conforme autos de exibição e apreensão (fls. 14, 16 e 17) e laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 104/107).

Segundo o apurado, os denunciados guardavam a droga apreendida num matagal próximo à residência para comercialização.

A polícia recebeu denúncias anônimas sobre tal fato e passou a investigar. Em campanha, visualizou DJALMA dirigindo-se até o matagal e escondendo a droga ali. Diante disso, a polícia entrou na residência e abordou os denunciados.

Com ALISSON foram encontradas três porções de "maconha". Na pia da cozinha apreendeu-se a quantia de R\$ 126,00. No matagal foi descoberto o restante da droga apreendida, consistente em um "tijolo" da mesma droga.

Regularmente notificados, os denunciados apresentaram defesas prévias, refutando o teor da denúncia e arrolando testemunhas (fls. 183/190 e 197/203).

Recebida a denúncia, e em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 209 e 216).

Na solenidade, colheram-se os depoimentos das testemunhas, e os réus foram interrogados. Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente (termo e mídia audiovisual da audiência).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A materialidade delitativa está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 2/4), nos autos de exibição e apreensão (fls. 14/17) e no laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 104/107). Depreende-se de tais elementos cognitivos que foram apreendidos na residência do acusado Djalma, no matagal próximo ao local e em poder do corréu Alisson 92,17 g de Cannabis sativa L., vulgo "maconha", com peso líquido de 92,17g, além de R\$ 126,00 em espécie. O exame químico-toxicológico atestou que a substância entorpecente apreendida é causadora de dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, conforme a Portaria nº 344/1998 da Secretária da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria também é certa e recai sobre os acusados, exsurgindo da prova vocal produzida judicialmente, sob o crivo do contraditório (mídia audiovisual da audiência).

Paulo Rogério Cardoso, policial civil, ouvido como testemunha, relatou que denúncias anônimas davam conta de que os increpados traficavam nas imediações da casa de Djalma. Segundo os informes, os réus se utilizavam do matagal para esconder drogas. No dia dos fatos, após campanha policial, perceberam Djalma indo em direção ao aludido matagal e escondendo um embrulho ali. Ato contínuo, a equipe policial notou a movimentação suspeita e conseguiu abordar Alisson e Djalma. Com Alisson, foram encontradas três porções de maconha, além de R\$ 126,00 em espécie. Em revista ao matagal, conseguiram localizar o embrulho, consistente em uma porção maior de maconha. Uma equipe foi para a casa de Djalma, enquanto outra equipe abordou Alisson dentro da residência. O local era ponto de traficância. Alisson disse que a droga se destinava ao próprio uso.

Lino Francisco Mourão Gregghi, também policial civil, compromissado, reportou que receberam denúncias anônimas narrando que os acusados estavam traficando e escondiam as drogas próximo a uma ponte de madeira, nas imediações da casa de Djalma. Fizeram campanha no local. Avistado, Alisson correu para dentro da residência e foi abordado, na posse de três porções de maconha. Foram localizados R\$ 126,00 em espécie na casa de Djalma. No matagal, foi encontrado um tijolo de maconha. Observaram Djalma guardando o tijolo no mato e retornando para a residência.

Lucas Barbosa de Castro contou que passava sempre pelo local dos fatos, por onde transitam várias pessoas, inclusive usuários de drogas.

Interrogados, os réus negaram os fatos. Alegaram, em suma, ser usuários de drogas. Disseram que estavam consumindo drogas conjuntamente na oportunidade.

Com efeito, a par de os depoimentos dos policiais civis serem seguros, claros e congruentes, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra deles tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar os réus, em razão, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Sobre tudo em casos como o presente, envolvendo tráfico de drogas, há de se atribuir especial realce aos depoimentos dos

policiais que efetuaram a diligência e têm o dever legal de preservar a ordem pública. Não se patenteou a intenção dos agentes policiais em incriminar gratuitamente os acusados – até porque nem sequer os conheciam pessoalmente – e/ou mero interesse em justificar a abordagem e a prisão. A localização, pelos policiais civis, dos entorpecentes e do dinheiro em espécie no interior do imóvel resultou de regular diligência investigativa, precedida de campana.

Embora as defesas técnicas, alinhadas aos interrogatórios judiciais dos acusados, meneiem a evasiva e surrada tese de que eles são meros usuários de drogas, pleiteando a desclassificação para posse para uso próprio, a argumentação não merece maior credibilidade. A distinção entre os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de posse para uso próprio (art. 28 da mesma Lei) é balizada, no caso concreto, pelos critérios estampados no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. Em que pese a quantidade do entorpecente apreendido não seja tão expressiva, as condições em que se desenvolveu a ação – as drogas foram apreendidas no curso de diligências que vincularam, em linha de princípio, o local dos fatos e os seus habitantes ao narcotráfico – assinalam com o comércio ilícito de entorpecentes. Mais a mais, os dependentes de drogas não só as consomem como, amiúde, comercializam-nas para manter o vício (confirmam-se, por todas: TJSP, Apelação Criminal nº 1500186-28.2018.8.26.0150, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 08.04.2021; e TJSP, Apelação Criminal nº 1501307-44.2021.8.26.0594, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xisto Rangel, j. 08.08.2022).

Tampouco se concebe que a droga tenha sido forjada pelos policiais civis. Foi apreendida quantidade não tão ínfima de substância entorpecente, sendo que um flagrante por tráfico poderia ser fabricado com uma quantidade inferior, caso fosse esse o intento dos agentes públicos.

Também ao revés do alegado pelos doutos defensores em suas alegações finais, não se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita das drogas para que os agentes sejam responsabilizados criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 que ele tenha em depósito ou guarde narcóticos destinados ao comércio ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). De resto, as defesas não comprovaram qualquer fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhes incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não vinga a tese da absolvição por falta de provas da materialidade e autoria delitivas.

Noutro giro, é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado, benefício positivado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Os agentes são tecnicamente primários, não ostentam maus antecedentes (certidões de fls. 54/55 e 59/60), e não há qualquer sinal de que se dediquem a atividades

criminosas e/ou de que integrem organização criminosa. Não bastam para comprovar tal dedicação criminosa ilações derivadas de alusão feita pelos policiais civis a pretensas denúncias anônimas envolvendo os agentes.

Simetricamente, do envolvimento de Alisson em atos infracionais não é possível concluir que se dedica a atividades criminosas. A resposta estatal para as situações que cercam as crianças e os adolescentes funda-se em premissas diversas, anteriores à imputabilidade penal. Assim, por não configurarem crime ou contravenção penal, não se afigura razoável que possam ser consideradas como envolvimento em atividades criminosas, a ponto de se afastar a incidência do redutor. Aliás, se “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139 do STJ), com maior razão, a prática infracional anterior não se erige em obstáculo ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito para aplicação da pena base em seu mínimo legal; afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos III e VI, do artigo 40, da Lei de Drogas; reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.

2. Dosimetria que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa. Súmula n. 231 do STJ. Envolvimento de adolescente aumento da pena em 1/6. Afastamento da causa de aumento referente à prática do crime nas proximidades de escola. Ausência de croqui ou qualquer outro documento que comprovasse a eventual existência ou mesmo distância entre o local dos fatos e o estabelecimento de ensino. Crime que foi praticado em época de férias escolares. Atos infracionais anteriores que não se prestam a revelar o envolvimento do réu em atividades criminosas. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena no patamar máximo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime inicial aberto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500213-24.2019.8.26.0144, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 29.04.2022); e

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa apenas com relação à aplicação da pena.

Mérito. Materialidade e autoria devidamente demonstradas. Dosimetria. Terceira fase. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento das condutas na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não podem ser usados como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas. Precedentes do STJ e do STF. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recurso provido. (Apelação Criminal nº 1500592-19.2020.8.26.0535, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Semer, j. 25.04.2022).

No tangente ao patamar de diminuição da pena, malgrado o § 4.º do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração redutora, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram a compreensão de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado -

balizas do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 -, servirão para a escolha do quantum da redução. Considerando que foi apreendida quantidade não portentosa de droga de mesma natureza (maconha) e que não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social do réu, reputo adequado e proporcional a redução da pena no patamar máximo (2/3). Nesse aspecto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Recurso objetivando a aplicação do redutor no grau máximo e a substituição da carcerária por restritivas de direitos. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório coeso. Confissão. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. Condições pessoais favoráveis que comportam a incidência do redutor no grau máximo, a fixação do regime aberto, que melhor se adequa às finalidades preventiva e retributiva da pena, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500290-05.2020.8.26.0530, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 16.03.2021); e

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Primariedade. Redutor legal específico. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena restritiva de direitos. Regime prisional inicial. Regime aberto. Tratando-se de traficância não especialmente admirável de 160,6 gramas de drogas ilícitas, posto também praticada por agentes primários que não ostentam maus antecedentes, admissível o deferimento da assistência máxima do redutor específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com a substituição por restritivas de direitos das penas privativas de liberdade que, se o caso, haverão de ser inicialmente cumpridas no regime prisional aberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1508466-06.2020.8.26.0228, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e não descortinadas causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal dos acusados como incursos no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar conjuntamente as penas aplicáveis a eles, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, as circunstâncias discriminadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A natureza (maconha) e a quantidade não exorbitante das drogas não ensejam maior reprovação penal, e não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social dos agentes. Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade é inerente à espécie. Os réus são primários. As circunstâncias, as consequências e os motivos do crime são próprios do tipo penal, não justificando maior reprimenda. E está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo as penas-base no piso de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa em relação a Alisson (art. 65, I, do Código Penal). Não diviso, por outro lado, agravantes. Entretanto, a fim de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada para Alisson, em atenção ao disposto na Súmula nº 231 do STJ, remanescendo as basílicas inalteradas.

Na terceira fase, concorre a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro as penas em 2/3 (dois terços) - na esteira do acima explanado -, e, à míngua de causas de aumento, torno-as definitivas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

A Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1.052.700/MG, reafirmou o entendimento gizado de forma incidental pelo Plenário, no julgamento do HC 111.840/ES, de que é inconstitucional o art. 2º, § 1º, da lei 8.072/1990:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE

DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.

A dizer: a gravidade abstrata do tráfico de drogas, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo – compreensão que está em consonância com as Súmulas nºs 718 e 719 do STF.

Mais recentemente, sufragando a posição consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do HC nº 596.603-SP, publicado em 22.09.2020, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Faustino Neto, condenado como incurso no art. 33, “caput” e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedeu ordem individual e coletiva, constando da parte dispositiva:

1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar o regime aberto como modo inicial de cumprimento da pena.

2. Em relação aos presos que se encontrem em situação igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos que procedam à mudança do regime de pena para o aberto.

3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo os casos do item anterior determinar que os respectivos juízes das Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela execução das sanções dos internos reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um, de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime inicial em face de eventual detração penal decorrente do período em que tenham permanecido presos cautelarmente.

4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A Corte Superior de Justiça estabeleceu diretrizes a serem observadas pelos juízes e tribunais de todo o País, dentre as quais:

2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD)

2.c. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução nº 5 do Senado Federal, decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF).

Nessa ordem de ideias, fixo o regime aberto para início do resgate das penas corporais, porquanto inferiores ao patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, e haja vista que os réus não são reincidentes (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), sendo favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 3º, sempre do Código Penal). Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; réu não reincidente em crime doloso; e suficiência e adequação da substituição da pena corporal, diante das circunstâncias judiciais, para atingir as finalidades da sanção), substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos (§ 2º do mesmo artigo), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a quatro salários- mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de

instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Em abono ao motivado, colho precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos aos dos autos:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; b) fixação do regime inicial aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prequestionamento.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio.

2. Dosimetria da pena que merece reparo. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo. Atos infracionais que não constituem elemento impeditivo à aplicação da causa de diminuição. Precedentes.

3. Regime fechado. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Afastamento do caráter hediondo. Precedentes no STF e STJ. Regime aberto que se mostra adequado.

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade diante do afastamento do caráter hediondo. Condições subjetivas favoráveis do réu.

5. Pleito de prequestionamento. Desnecessidade de indicação dos fundamentos legais de forma expressa na motivação do acórdão para fins de prequestionamento, desde que haja efetivo debate sobre a matéria. Prequestionamento implícito. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Criminal nº 1501204-56.2020.8.26.0599, 16ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 17.05.2021); e

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de afastamento do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da imposição do retiro pleno - Inviabilidade dos pedidos - Presentes os requisitos do "tráfico privilegiado", deve ser mantida o redutor, bem como os demais benefícios - RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500221-38.2018.8.26.0628, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 17.05.2021).

Substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR os acusados DJALMA LUIZ DE BRITO OLIVEIRA e ALISSON RAMOS RODRIGUES DA SILVA, já qualificados nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de: (a) 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que ora substituo por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor equivalente 4 (quatro) salários-mínimos à época dos fatos, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos). Considerando que os réus foram colocados em liberdade provisória e apenados com sanções privativas de liberdade a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, devidamente substituídas por medidas alternativas, cenário incompatível com a prisão preventiva (vide, por todas, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência), e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito deles de recorrerem também em liberdade (art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal

(art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso).

Condene os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 CPP).

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder dos agentes em favor da União – consoante fundamentação supra -, o que faço com fulcro no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.343/2006. Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Sobrevindo o trânsito em julgado: (a) lancem-se os nomes dos réus no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral dos acusados, para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária à execução das penas; (d) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais dos acusados; e (e) calculada a multa, intuem-se os acusados para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Cumpridas as demais atribuições cartorárias de praxe, arquivem-se os autos definitivamente, promovendo-se as baixas nos registros.

P. I. C.

Piraju, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA